

刑法
No47

共通問題 H26-13

(配点: 3)

月 日

月 日

故意に関する次の各【見解】についての後記1から5までの各【記述】のうち、正しいものを2個選びなさい。

【見 解】

A説：故意の有無については、構成要件を基準にして判断すべきであり、殺人罪においては、行為者の認識した事実と発生した事実が、およそ「人を殺す」という点で一致していれば故意が認められる。

B説：故意の有無については、構成要件を基準にして判断すべきであるが、殺人罪においては、行為者の認識した事実と発生した事実が、「その人を殺す」という点で一致していなければ故意は認められない。

【記 述】

1. A説に対しては、客体の錯誤と方法の錯誤の区別が必ずしも明らかではない場合があり、その場合の故意の有無につき、どのように判断するのか明確ではないとの批判がある。
2. B説に対しては、故意以外の構成要件該当性は法益主体ごとに判断するのに、故意の有無についてのみ法益主体の相違を問題にしないのは論理的でないとの批判がある。
3. 侵害が生じた客体に錯誤はないが、侵害に至る因果関係に錯誤がある場合の故意の有無について、A説かB説かによる差はない。
4. 駅のホームにいた人を甲だと思い、甲を殺そうと考え、電車が近づいてきたときにその人をホームから突き落として死させたところ、その人が甲ではなく、別人の乙であった場合、A説・B説のいずれによっても、乙に対する殺人罪の故意が認められることになる。
5. 狩猟中、動く物体を見付け、これを日頃から恨みを抱いていた甲だと思い、甲を殺そうと考え、その動く物体を狙って猟銃を発砲し、これに弾丸を命中させたが、実際に弾丸が命中したのは、甲ではなく、甲の飼い犬であった場合、A説によれば器物損壊罪の故意が認められ、B説によれば同罪の故意が認められないことになる。

1 誤っている ★

A説は、認識事実と発生事実とが構成要件の範囲内において重なり合っている場合に、実際に発生した構成要件該当事実について故意を肯定するという法定的符合説である。A説によると、構成要件の枠内の具体的事実に関する主観面・客観面の食い違いは、故意の観点からは重要でないことになり、客体の錯誤（甲だと思って殺したところ実は乙であったような場合）と方法の錯誤（甲を狙ったところ隣の乙を殺してしまった場合）のいずれについても故意が認められることになる。これに対し、B説は、被害者の相違を重視する具体的符合説であり、客体の錯誤は重要でないが方法の錯誤は重要であるとする見解である。この見解に対しては、方法の錯誤と客体の錯誤は、その定義自体も明確でなく、両者の限界が非常に曖昧であることが指摘されており、故意の有無につきどのように判断するのか明確でないとの批判がある。

2 誤っている

B説は、構成要件該当事実の認識・予見である故意の判断に際しては、被害者たる法益主体の相違を無視し得ない重要なものと捉える見解である。そのため、故意の有無についてのみ法益主体の相違を問題にしないのは論理的でないとの批判は当たらない。これに対し、A説は、構成要件の重要性と錯誤の重要性の判断基準とを異なるものとして捉えるものであり、故意以外の構成要件該当性は法益主体ごとに判断するのに、故意の有無についてのみ法益主体の相違を問題にしないのは論理的でないとの批判が向けられる。

3 正しい

客体に錯誤はないということは、例えば甲を殺そうと思って甲を殺したという点で行為者の認識事実と発生事実が一致しており、故意の有無についてA説とB説とで差はない。また、因果関係の錯誤は、法定的符合説か具体的符合説かによって故意の有無につき差は生じない。

4 正しい

本記述では、行為者が相手を甲と思って別人である乙を死亡させているが、「その人」をホームから突き落としてれき死させたという点において、行為者の認識事実と発生事実是一致的である。この場合は、A説とB説のいずれによっても、乙に対する殺人罪の故意が認められることになる。

5 誤っている

本記述における事情は、行為者が認識・予見した事実が該当する構成要件（殺人罪、199条）と発生した事実が該当する構成要件（器物損壊罪、261条）とが異なる場合、すなわち抽象的事実の錯誤に当たる。この場合、A説は、行為者の認識事実と発生事実が構成要件の範囲内で符合していれば故意を認める見解であるから、錯誤により認識した構成要件を超えた事実についての故意犯の成立は否定される。ただし、A説によっても、異なる構成要件が同質的なもので重なり合うと認められる場合には、その限度で軽い罪の故意犯の成立を認めるという修正が加えられているが、本記述において殺人罪と器物損壊罪の構成要件は重なり合わないため、結局、行為者に器物損壊罪の故意は認められない。なお、本記述において、重い罪の故意で軽い罪の結果を生じさせたものとして、軽い罪（器物損壊罪）の故意を認めるのは、抽象的符合説である。